

刑法
No132

R3-13

(配点: 2)

月 日

月 日

次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】のうち、甲に殺人未遂罪の成立を認めるための論拠として適切なものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、知人の乙に、毒物を混入したワイン（以下「本件ワイン」という。）を送り付ければ、乙がそれを自ら飲んで死亡すると考えた。甲は、某日、本件ワインを宅配業者の事務所に持ち込み、3日後の配達指定をして、乙宅への配達を申し込んだ。しかし、本件ワインは、申込み当日、同事務所での保管中に瓶が破損して廃棄処分となったため、乙宅に配達されることはなかった。

【記述】

ア. 間接正犯の実行の着手については、被利用者の行為を基準として実行の着手を判断すべきところ、本件では、それと同様の考え方が妥当する。

イ. 結果発生の一定の蓋然性が生じれば、未遂犯の成立を認めることができる。我が国の一般的な宅配業務の実情を前提とした場合、本件ワインの配達を申し込んだ時点で乙宅に到着することはほぼ確実といえる。

ウ. 実行の着手は、行為者が、その犯行計画上、構成要件実現のためになすべきことを行った時点で認めることができる。

エ. 甲が、宅配業者に依頼せず、自ら乙宅に本件ワインを届けようとした場合には、乙宅に本件ワインを届けるまでは殺人未遂罪が成立しないこととの均衡を考慮する必要がある。

オ. 既遂結果発生の時間的に切迫した危険を内容とする未遂結果は、刑法第43条の書かれざる構成要件要素である。

1. ア エ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. ウ オ

No132

殺人未遂罪

正答率

R3-13

正解

3

96%

ア 論拠とならない

本記述のように、「間接正犯の実行の着手については、被利用者の行為を基準として実行の着手を判断すべきところ、本件では、それと同様の考え方が妥当する。」と考えると、【事例】の被利用者である宅配業者が乙宅に本件ワインを届けた時点で実行の着手を認めることになる。しかし、【事例】では、本件ワインは乙宅に配達される前に、宅配業者の事務所で廃棄処分になったのだから、殺人罪の実行の着手は認められない。したがって、本記述は、甲に殺人未遂罪の成立を認めるための論拠とならない。

イ 論拠となる

本記述のように、「結果発生の一定の蓋然性が生じれば、未遂犯の成立を認めることができる」ところ、我が国の一般的な宅配業務の実情を前提とした場合、本件ワインの配達を申し込んだ時点で乙宅に到着することはほぼ確実といえる。」と考えると、【事例】の甲が本件ワインの乙宅への配達を申し込んだ時点で乙殺害結果発生の一定の蓋然性が生じており、未遂犯の成立を認めることができる。したがって、本記述は、甲に殺人未遂罪の成立を認めるための論拠となる。

ウ 論拠となる

本記述のように、「実行の着手は、行為者が、その犯行計画上、構成要件実現のためになすべきことを行った時点で認めることができる。」と考えると、【事例】の甲の犯行計画の実現のために甲がなすべきことは、宅配業者に本件ワインの乙宅への配達を申し込むことであり、これを行った以上、甲には殺人罪の実行の着手を認めることができる。したがって、本記述は、甲に殺人未遂罪の成立を認めるための論拠となる。

エ 論拠とならない

本記述のように、「甲が、宅配業者に依頼せず、自ら乙宅に本件ワインを届けようとした場合には、乙宅に本件ワインを届けるまでは殺人未遂罪が成立しないこととの均衡を考慮する必要がある。」と考えると、宅配業者を利用する場合も、乙宅に本件ワインを届けるまでは殺人未遂罪が成立しないと考えるべきである。そして、【事例】の本件ワインは乙宅に届く前に廃棄処分になったのであるから、甲に殺人未遂罪の成立を認めるべきではない。したがって、本記述は、甲に殺人未遂罪の成立を認めるための論拠とならない。

オ 論拠とならない

本記述のように、「既遂結果発生の時間的に切迫した危険を内容とする未遂結果は、刑法第43条の書かれざる構成要件要素である。」と考えると、既遂結果発生の時間的に切迫した危険が発生した時点で未遂犯が成立すると考えることになる。【事例】では本件ワインが乙宅に届く前に廃棄処分になっているため、乙殺害という既遂結果発生の時間的に切迫した危険が発生しておらず、未遂犯は成立しないことになる。したがって、本記述は、甲に殺人未遂罪の成立を認めるための論拠とならない。

以上により、甲に殺人未遂罪の成立を認めるための論拠として適切な記述はイとウであり、したがって、正解は肢3となる。